

1501608-79.2021.8.26.0597

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/07/2022

... conhecido nos meios policiais pelo intenso tráfico de drogas, também já era conhecido como traficante, e estava também na posse de dinheiro trocado, conclui-se que a droga apreendida efetivamente era destinada ao tráfico.

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Jardim América, Sertãozinho - SP -

cep 14160-260

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1501608-79.2021.8.26.0597

Controle: 2021/000758

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2088369/2021 - DISE- DEL.SEC.SERTÃOZINHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR

Aos 18 dias do mês de julho de 2022, às 14:30 horas, foi aberta a audiência, nos autos da ação supra referida realizada por meio virtual semipresencial, através do aplicativo Teams. Aberta com as formalidades legais, foram apregoadas as partes que participaram da videoconferência. A gravação será disponibilizada no sistema informatizado SAJ-PG5, conforme Comunicado Conjunto 1350/2020. Pelas partes foi manifestada concordância para que as gravações fossem feitas de forma individualizada, em arquivos separados de acordo com o número de testemunhas, visando facilitar futuros acessos. Sob a presidência do Meritíssimo Juiz de Direito, Dr. ANGEL TOMAS CASTROVIEJO, comigo Escrevente abaixo assinado, COMPARECERAM de forma virtual através do aplicativo TEAMS o Promotor de Justiça, Dr. JOÃO GUIMARÃES COZAC; o réu Marcos Aurélio de Oliveira Lima Júnior, seu Defensor nomeado, Dr. GUSTAVO LUIZ MARIOTO CAMARGO (OAB/SP 391762) e a testemunha arrolada pela acusação Guarda Civil Municipal Danilo Carvalho de Ataíde; COMPARECEU presencialmente ao prédio do fórum desta comarca: a testemunha arrolada pela acusação Guarda Civil Municipal Felipe Accorsini Palmieri, Iniciados os trabalhos, o MM. Juiz inquiriu as testemunhas arroladas pela acusação Guardas Cíveis Municipais Felipe Accorsini Palmiere e Felipe Accorsini Palmiere, qualificadas em videoconferência; pelo método audiovisual (artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações e depoimentos foram captados em áudio e vídeo através do aplicativo TEAMS, conforme acima citado. A seguir o MM. Juiz interrogou o réu Marcos Aurélio de Oliveira Lima Júnior, pelo método audiovisual

(artigo 405, § 1º, do Código de Processo Penal, e item 77, Capítulo II, NGSCJ), conforme gravação no sistema SAJ. E, não havendo outras provas a serem produzidas, o MM. Juiz declarou encerrada a instrução processual e passou aos debates orais. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça e ao Dr. Defensor, a explanação de cada um também foi captada em meio audiovisual através do aplicativo TEAMS e registrada no sistema SAJ. As partes dispensaram cópia em mídia CD (artigo 405, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal). A seguir pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte SENTENÇA:

Vistos.

MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque, no dia 19 de março de 2021, por volta das 23h00, na Rua João Manoel do Nascimento nº 50, Conjunto Habitacional Vila Áurea Mendez Gimenez, nesta cidade e comarca de Sertãozinho, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de mercancia e entrega a terceiros, 70 (setenta) cápsulas do tipo eppendorff contendo Cocaína e pesando 51,28g, substância capaz de determinar a dependência física e psíquica.

Segundo a denúncia, na data dos fatos a Guarda Civil Municipal realizava um patrulhamento rotineiro no local dos fatos, notório por se tratar de um ponto de venda de drogas, quando avistaram o acusado, já conhecido nos meios policiais pelo seu envolvimento com tal crime. Assim que os guardas decidiram abordá-lo, Marcos empreendeu fuga e arremessou no solo uma sacola plástica que levava consigo. Ela foi apreendida, e em seu interior foram encontradas 70 (setenta) cápsulas do tipo eppendorff contendo cocaína. Durante a fuga, ele também deixou cair no chão a quantia de R\$ 62,00 (sessenta e dois reais) e seu aparelho celular, junto do qual estava sua carteira de habilitação.

Recebida a denúncia em 29 de novembro de 2021 (fls. 51/52), o réu foi citado (fls. 57) e apresentou resposta à acusação (fls. 77/78).

Durante a instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelas partes, sendo o réu interrogado ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação do acusado, nos termos da denúncia.

A Defesa do acusado requereu que a absolvição, com fundamento no art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, por falta de provas de que a droga apreendida fosse do réu, sustentando, em síntese, que o réu apenas retornava para sua casa com um refrigerante, que não estava na posse da droga, e que correu apenas porque percebeu que seria a ele imputada indevidamente a propriedade das drogas encontrada em via pública. Subsidiariamente, requereu o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, a fixação do regime aberto, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal é procedente.

A materialidade do delito encontra-se comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 06/07), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 08/09), pela imagem fotográfica (fls. 10), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 15/17), conclusivo por se tratar de cocaína, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também foi devidamente comprovada pelas provas produzidas nos autos. Os guardas municipais Felipe e Danilo, tanto na fase policial quanto em Juízo, disseram que local dos fatos, o qual já é conhecido pelo comércio ilícito de drogas, avistaram o acusado, pessoa conhecida nos meios policiais por ser envolvida com o tráfico de drogas. Decidiram abordá-lo, momento em que ele empreendeu fuga e jogou no chão uma pequena sacola plástica que estava em suas mãos, a qual, posteriormente verificada continha 70 eppendorfs de cocaína. Na fuga, o acusado deixou cair o dinheiro que estava consigo, bem como seu aparelho celular, no qual estava, junto à capinha, sua Carteira Nacional de Habilitação. Em Juízo, ressaltaram que a abordagem foi motivada pela conduta suspeita do réu que, ao ver a aproximação da viatura, dispensou uma sacola plástica que trazia consigo. Também disseram que não conseguiram abordar o réu. O Guarda Danilo disse também ter

conhecimento de que a casa do pai do réu fica próximo do local da abordagem (fls. 12, 13 e mídia).

O réu, ao ser interrogado na fase policial, negou a prática delitiva, alegando que na noite dos fatos estava na casa de seu pai, a qual é próxima do local onde foi abordado. Seu pai lhe deu R\$ 100,00 para que comprasse um refrigerante e então foi até um bar lá próximo, sendo que no caminho teve que passar por um local que sabe ser ponto de venda de drogas. Quando estava voltando, acabou sendo abordado por Guarda Municipais, os quais revistaram-no e encontraram o dinheiro trocado da compra do refrigerante, ou seja, R\$ 91,00. Alega que um dos guardas chegou a chutar seu refrigerante quando da abordagem. Os guardas perguntaram o que estava fazendo, sendo que narrou sobre a compra do refrigerante e, então, eles disseram que se encontrassem algo escondido ali perto, iriam dizer que era dele. Os guardas passaram a fazer buscas no local e um dos guardas virou a esquina, nessas buscas. Pouco depois, ele retornou dizendo para o colega dele que era para algemar o interrogando, pois ele havia encontrado drogas. O interrogando disse que a droga não era de sua propriedade, mas o guarda foi tentar algemá-lo. Para não ser preso injustamente, saiu correndo. Alega que a droga encontrada não é sua, bem como não é traficante. Esclarece que seu pai mora na Rua Sebastião Gonçalves nº 307 e o interrogando reside na Av. João Pignata nº 155. Nunca residiu na Rua João Manoel do Nascimento nº 50, não sabendo o motivo desse endereço constar no Boletim de Ocorrências. No momento, está fazendo "bicos" no Motel Acqua Village de Sertãozinho, trabalhando na lavanderia. Afirma não possuir passagens criminais (fls. 43).

Em Juízo, reiterou a negativa. Alega que estava num churrasco na casa de seu pai, e quando estava voltando de um bar e levando bebida, foi abordado por guardas, que passaram a indaga-lo o que fazia no local e não acreditaram em alegação de que estava apenas levando bebida ao churrasco de seu pai. Enquanto conversava com um guarda o outro passou a procurar pelas imediações e encontrou as drogas apreendidas. No momento em que o guarda imputou ao interrogando a propriedade das drogas, resolveu sair correndo, deixando com um dos guardas o celular e a CNH que havia anteriormente entregue a ele. Não conhecia os guardas anteriormente (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o acusado era realmente o proprietário da droga apreendida e que se destinaria à comercialização.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas guardas municipais, em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido pelo intenso tráfico de drogas, avistaram o réu, que empreendeu fuga ao notar a aproximação dos guardas, dispensando ao solo uma sacolinha plástica contendo 70 eppendorfs de cocaína, e também na fuga deixou cair um celular contendo na capinha dinheiro troco e sua CNH. O réu, por sua vez, negou a prática delitiva, alegando que apenas tinha ido com refrigerante a pedido de seu genitor, que fazia um churrasco em sua casa, que fica próxima ao local da abordagem, e que correu apenas porque, após abordado, um dos guardas quis imputar ao réu, indevidamente, a droga que havia encontrado nas imediações.

Contudo, tal versão não convence.

Isso porque, diversamente do alegado, os guardas confirmaram de forma firme e harmônica que viram o exato momento em que o réu dispensou a sacola onde estavam os entorpecentes, fato este ainda que teria motivado sua abordagem. Também não há respaldo em qualquer prova dos autos a alegação do réu de que primeiramente foi abordado pelos guardas, e que estes somente após passaram a vasculhar pelo encontro de drogas, ou ainda que realmente estivesse frequentando um churrasco naquela data. Assim, considerando a significativa quantidade de droga encontrada na posse do réu, superior ao que normalmente é encontrado com meros usuários, bem como a forma como estavam acondicionadas, e que o réu foi abordado em local conhecido nos meios policiais pelo intenso tráfico de drogas, também já era conhecido como traficante,

e estava também na posse de dinheiro trocado, conclui-se que a droga apreendida efetivamente era destinada ao tráfico.

De resto, é de maciça jurisprudência, prolatada inclusive pelas Cortes Superiores quanto a suficiência da prova testemunhal consistente em depoimentos de policiais ou de guardas municipais para embasar a condenação em crimes de tráfico de drogas como o tratado nos autos. Não havendo qualquer indício nos autos quanto à suspeição desses agentes públicos, estes depoimentos são aptos como meio de prova:

“O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos.” (STF – HC nº 73.518-5 – Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

“HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. Precedentes. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes. 3. Ordem denegada.” (STJ Min. Laurita Vaz 5ª Turma HC nº Relator: Salles Abreu Apelação nº 0034020-74.2011.8.26.0602 Voto nº: 115516/SP 03/02/2009).

A propósito, já se decidiu no Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: TRÁFICO – Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade do delito – Coeso testemunho dos policiais militares – Validade – Ausência de dúvida que justifica o édito condenatório – Desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas – Tráfico caracterizado – Condenação mantida – PENA – redutor no patamar máximo – necessidade – Possibilidade de substituição da corporal por restritivas de direitos e fixação do regime aberto – Recurso parcialmente provido. (TJSP – Apelação 0000529-77.2015.8.26.0621 – Relator(a) Desembargador(a) Newton Neves – d.j. 20.02.2018).

APELAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. REGIME FECHADO. INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO, COM EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO. (TJSP – Apelação Criminal n. 0025717-46.2012.8.26.0114 – Relator(a) Desembargador(a) Airton Vieira – d.j. 05.12.2017).

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS NO CURSO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – PROVA ORAL INCRIMINADORA – A JURISPRUDÊNCIA É PACÍFICA AO RECONHECER A VALIDADE DO TESTEMUNHO DOS POLICIAIS MILITARES – O ORDENAMENTO PÁTRIO CONSAGROU O CRITÉRIO DO RECONHECIMENTO JUDICIAL EM RELAÇÃO AO CRIME DO PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO E NÃO O DA QUANTIFICAÇÃO LEGAL PARA A CARACTERIZAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – DESTINAÇÃO COMERCIAL DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS DELINEADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSIMETRIA PENAL INALTERADA – REGÊNCIA PRISIONAL MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJSP – APELAÇÃO nº 0000219-84.2016.8.26.0573 – Relator(a) Desembargador(a) Euvaldo Chaib – d.j. 14.11.2017).

“PROVA - Testemunha - Policial - Validade - Inexistindo indícios de que policiais tivessem interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa o réu, ausentes, ainda, elementos que indiquem perseguição policial, de afastar-se eventual suspeita

sobre o depoimento ofertado, considerando-se, também, que na condição de funcionários públicos que são, gozam de fé pública e seus depoimentos elevem ser aceitos como verdadeiros máxime quando encontram eco nos demais elementos colecionados nos autos - Recurso parcialmente provido". (Apelação Criminal n. 993.07.113380-9 - Ibitinga - 14ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Alfredo Fanucchi - 14.08.08 - V.U. - Voto n. 8007).

"PROVA - Depoimento policial - Valor - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - O depoimento de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como qualquer outro testemunho - A circunstância de ser policial a testemunha, não afeta, positiva ou negativamente, o valor probante de sua palavra - Precedentes do Col. Supremo Tribunal Federal - Recurso improvido neste aspecto" (Apelação Criminal n. 993.08.043553-7 - São Paulo - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton Neves - 09.09.08 - V.U. - Voto n. 5652).

"PROVA - Depoimento de policial - Validade - Testemunhos prestados por policiais que procederam à prisão do acusado - Eficiência - Hipóteses de suspeição e impedimento com previsão legal exaustiva - Ocorrência - Apelação provida parcialmente" (Apelação Criminal n. 1.002.701-3/7 - São Paulo - 9ª Câmara do 5º Grupo da Seção Criminal - Relator: René Nunes - 28.02.07 - M.V. - Voto n. 10.200). A acusação formulada na denúncia, portanto, foi devidamente confirmada pelas provas produzidas durante a instrução criminal, não se podendo alegar insuficiência probatória.

Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação do réu como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base do réu no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas na segunda fase.

Na terceira fase, inicialmente observo que a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, notadamente a fração a ser aplicada, deve observar as diretrizes previstas no art. 42 da mesma lei, que impõe seja considerado, na fixação das penas, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Neste sentido:

"O art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 impõe ao Juiz considerar, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da droga, tanto na fixação da pena-base quanto na aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4.º do art. 33 da nova Lei de Tóxicos. 3. Não se trata de violação ao princípio do non bis in idem, mas apenas da utilização da mesma regra em finalidades e momentos distintos. Com efeito, na primeira etapa da dosimetria, os critérios do art. 59 do Código Penal e do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006 servem para fundamentar a pena-base, enquanto no último momento do sistema trifásico os mesmos parâmetros serão utilizados para se estabelecer a fração de redução a ser aplicada em razão da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei Antitóxicos. (...) 6. Ordem denegada." (STJ - HC n.º 165800/RS, 5ª Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje. 15.03.2012).

Assim, levando em conta que o réu é primário e não ostenta maus antecedentes, também não havendo provas de que integre organização criminosa, reduzo as penas acima indicadas em 2/3 (dois terços), totalizando 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Relativamente ao regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, cumpre observar o que foi decidido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do HC

97.256/RS.

Em referido julgado o Supremo Tribunal Federal concedeu parcialmente a ordem pleiteada e decidiu pelo cabimento de pena alternativa, removendo o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, julgado inconstitucional nesta parte, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal.

Assim foi redigida a ementa do julgado:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 44 DA LEI 11.343/2006: IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA (INCISO XLVI DO ART. 5º DA CF/88). ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O processo de individualização da pena é um caminhar no rumo da personalização da resposta punitiva do Estado, desenvolvendo-se em três momentos individuados e complementares: o legislativo, o judicial e o executivo. Logo, a lei comum não tem a força de subtrair do juiz sentenciante o poder-dever de impor ao delinqüente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo. Implicando essa ponderação em concreto a opção jurídico-positiva pela prevalência do razoável sobre o racional; ditada pelo permanente esforço do julgador para conciliar segurança jurídica e justiça material.

2. No momento sentencial da dosimetria da pena, o juiz sentenciante se movimenta com ineliminável discricionariedade entre aplicar a pena de privação ou de restrição da liberdade do condenado e uma outra que já não tenha por objeto esse bem jurídico maior da liberdade física do sentenciado. Pelo que é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória.

3. As penas restritivas de direitos são, em essência, uma alternativa aos efeitos certamente traumáticos, estigmatizantes e onerosos do cárcere. Não é à toa que todas elas são comumente chamadas de penas alternativas, pois essa é mesmo a sua natureza: constituir-se num substitutivo ao encarceramento e suas seqüelas. E o fato é que a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal. As demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero.

4. No plano dos tratados e convenções internacionais, aprovados e promulgados pelo Estado brasileiro, é conferido tratamento diferenciado ao tráfico ilícito de entorpecentes que se caracterize pelo seu menor potencial ofensivo. Tratamento diferenciado, esse, para possibilitar alternativas ao encarceramento. É o caso da Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e de Substâncias Psicotrópicas, incorporada ao direito interno pelo Decreto 154, de 26 de junho de 1991. Norma supralegal de hierarquia intermediária, portanto, que autoriza cada Estado soberano a adotar norma comum interna que viabilize a aplicação da pena substitutiva (a restritiva de direitos) no aludido crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

5. Ordem parcialmente concedida tão-somente para remover o óbice da parte final do art. 44 da Lei 11.343/2006, assim como da expressão análoga “vedada a conversão em penas restritivas de direitos”, constante do § 4º do art. 33 do mesmo diploma legal. Declaração incidental de inconstitucionalidade, com efeito ex nunc, da proibição de substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos; determinando-se ao Juízo da execução penal que faça a avaliação das condições objetivas e subjetivas da convalidação em causa, na concreta situação do paciente.

(HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01/09/2010, DJe-247 DIVULG 15-12-2010 PUBLIC 16-12-2010 EMENT VOL-02452-01 PP-00113).

Seguindo a determinação do Colendo Supremo Tribunal, cuja decisão, por força da Resolução nº 05/2012 do Senado Federal, com fundamento no art. 52, X, da Constituição Federal, passou a ter efeito "erga omnes", cumpre avaliar as condições objetivas e subjetivas para a fixação do regime prisional e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Para tanto, o próprio Supremo Tribunal Federal observou neste julgado que cabe ao juiz sentenciante "o poder-dever de impor ao delinquente a sanção criminal que a ele, juiz, afigurar-se como expressão de um concreto balanceamento ou de uma empírica ponderação de circunstâncias objetivas com protagonizações subjetivas do fato-tipo". Ponderou também que "a pena privativa de liberdade corporal não é a única a cumprir a função retributivo-ressocializadora ou restritivo-preventiva da sanção penal; as demais penas também são vocacionadas para esse geminado papel da retribuição-prevenção-ressocialização, e ninguém melhor do que o juiz natural da causa para saber, no caso concreto, qual o tipo alternativo de reprimenda é suficiente para castigar e, ao mesmo tempo, recuperar socialmente o apenado, prevenindo comportamentos do gênero".

Assim sendo, analisando o caso concreto, reputo não socialmente recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2º, do Código Penal, para reprovação e prevenção do crime.

Destaco que o tráfico de drogas é de gravidade social elevada, notadamente em razão de suas sérias consequências, tão nefasto à saúde pública e à sociedade. Isso porque arrebatava vidas do seio familiar, causa danos à saúde pública, e afeta a psicologia de toda a sociedade. É o consumo de psicotrópicos que corrompe o indivíduo socialmente sã, aliciando-o para o cometimento de delitos contra o patrimônio, delitos domésticos, em evolução criminosa até culminar com crimes contra o bem constitucional vida, bem como responsável pela desestruturação de muitas famílias.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu MARCOS AURÉLIO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR, qualificado nos autos, à pena 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, "caput", c.c. § 4º, da Lei 11.343/06.

Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Fixo o regime inicial aberto para o cumprimento da pena, por força da decisão proferida pelo STJ no HC nº 596.603 SP (2020/0170612-1), podendo recorrer em liberdade diante da primariedade, considerando, outrossim, a ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da prisão preventiva.

Em face da condenação, o réu arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Pelo Réu e seu Dr. Defensor foi dito que RECORREM da r. sentença. Pelo Promotor de Justiça foi dito que CONCORDA com a r. sentença. Por fim, pelo MM. Juiz foi dito: "Recebo o recurso interposto pela defesa. Aguardo as razões. Após, ao Ministério Público para que apresente as contrarrazões. Apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça. Arbitro honorários advocatícios ao Defensor nomeado Dra. Gustavo Luiz Marioto Camargo (OAB/SP 419238) em 70% da tabela OAB/Defensoria, EXPEÇA-SE certidão. Oficie-se o necessário. Comunique-se. Publicada em audiência, saem intimados os presentes. Nada mais." Eu, _____, Marco Antônio Veiga, Escrevente Técnico Judiciário, digitei e subscrevi.